

论刑事庭审实质化^{*}

汪海燕

摘要：刑事庭审实质化是“以审判为中心的诉讼制度改革”的基本要求，其内核是被告人的刑事责任在审判阶段通过庭审方式解决。在一些地方的司法实践中，逮捕“绑架”审判，审理方式以审查案卷笔录为主，庭前会议实体化，以及法庭审理仅以定罪为中心，均在一定程度上虚置刑事审判程序，使其流于形式。在构建庭审中心裁判机制以及落实“权责一致”办案责任制的背景下，有必要消除庭审虚化的成因，建构审判中心主义的诉讼结构，实现直接言词原则的庭审方式，合理定位庭前会议功能，调整定罪与量刑并重的庭审内容，在诉讼制度层面实现我国刑事审判程序的实质化。

关键词：庭审实质化 逮捕中心主义 审判中心主义 言词审理 庭前会议

作者汪海燕，中国政法大学刑事司法学院教授，中国政法大学、吉林大学、武汉大学“2011计划”司法文明协同创新中心成员（北京 100088）。

一、引言

无论是为了实现实体公正和程序公正，还是落实权责一致的办案责任制，均要求被告人的刑事责任在审判阶段通过庭审方式解决，这是刑事庭审^①实质化的要义，也是“以审判为中心的诉讼制度改革”^②的落脚点。所谓刑事庭审实质化，是指应通过庭审的方式认定案件事实并在此基础上决定被告人的定罪量刑，其基本要求包括两个方面：一是审判应成为诉讼中心阶段，被告人的刑事责任应在审判阶段而不是在侦查、审查起诉或其他环节解决；^③另一个是庭审活动是决定被告人命运的关键。

* 本文为司法部国家法治与法学理论研究课题“刑事诉讼法解释研究”（12SFB3017）阶段性成果，并受中国政法大学刑事法学创新团队和中青年教师培养支持计划资助项目资助。

① 限于主题和篇幅，本文论述的庭审仅指刑事案件一审庭审程序。

② 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，北京：人民出版社，2014年，第23页。

③ 本文所讨论的“庭审实质化”，并不包含在侦查、审查起诉阶段“合法”分流的案件，以及通过简易程序和轻微案件速决程序审理的案件。

键环节,即“审判案件应当以庭审为中心。事实证据调查在法庭,定罪量刑辩护在法庭,裁判结果形成于法庭”。^①

庭审实质化是相对庭审虚化或形式化而言。所谓“庭审虚化”,是指案件事实和被告人刑事责任不是通过庭审方式认定,甚至不在审判阶段决定,庭审只是一种形式。我国刑事庭审虚化的问题由来已久。早在 1996 年《刑事诉讼法》修改时,理论界和立法者均认为当时庭审“先入为主”、“先判后审”、“先定后审”,导致开庭审判走过场。^②对此,1996 年《刑事诉讼法》改革开庭前的审查程序,将开庭前的实体性审查改为程序性审查,同时增强庭审对抗性。然而,这些改革并没有取得预期效果。2012 年《刑事诉讼法》修改时,立法者继续朝此方向努力,认为“审判是决定被告人是否构成犯罪和判处刑罚的关键阶段”,^③并改革庭前准备程序、证人、鉴定人出庭制度等。然而,时至今日,在一些地方的司法实践中,刑事庭审虚化的现象仍并非鲜见,如关于犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任问题,在审判前已经形成定论,法庭审判只是一个过场;控方审前阶段形成的案卷材料充斥庭审,甚至成为法院裁判的决定性依据;法庭审判以定罪为中心,量刑程序被虚置;等等。近期出现的一些冤案,如浙江叔侄奸杀案和内蒙古呼格吉勒图案等,均与“侦查中心”和庭审虚化有直接关系。正是在上述背景下,党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求“推进以审判为中心的诉讼制度改革,确保侦查、审查起诉的案件事实证据经得起法律的检验。全面贯彻证据裁判规则……完善证人、鉴定人出庭制度,保证庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用”。^④

诸多原因皆有可能导致刑事庭审的虚化,比如司法体制、诉讼制度和审判主体的个体素养等。从宏观的司法体制角度考察,法外因素的不当干预等可能造成“先定后审”;从微观的审判主体角度考察,法官个体素养不高,不是根据庭审证据材料而是考虑其他因素作出裁判,也会造成庭审程序的虚置。正因如此,治理刑事庭审虚化、实现庭审实质化为一项庞杂的系统工程。宏观的司法体制、微观的审判主体素质等,虽然是导致刑事庭审虚化的重要因素,但不是最直接的成因,因此无法构成解决刑事庭审虚化问题的主要抓手。本文试图从诉讼制度的角度阐述如何实现我国刑事庭审实质化。

① 《最高人民法院关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第 11 条。

② 参见胡康生、李福成主编:《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉释义》,北京:法律出版社,1996 年,第 171 页。

③ 王兆国:《关于〈中华人民共和国刑事诉讼法修正案(草案)〉的说明》,陈光中主编:《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉修改条文释义与点评》,北京:人民法院出版社,2012 年,第 512 页。

④ 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,第 23 页。

二、纵向诉讼结构：从“逮捕中心主义”到“审判中心主义”

一个案件的完整诉讼形态包括侦查、审查起诉和审判等主要阶段。关于侦查、审查起诉和审判三个阶段在诉讼中的地位，理论界和实务界主要有“侦查中心主义”、“三阶段并重论”和“审判中心主义”等论说。“侦查中心主义”，是指决定被告人命运的为侦查阶段，后续程序只是对侦查调查结果的补充、印证。其缺陷是，如果过分强调侦查在诉讼中的地位，就会“仅仅根据侦查阶段做成的调查笔录进行审判，即所谓‘书面审理’”，^①不仅虚置了被告人质证、辩论的权利，也使得庭审流于形式。“三阶段并重论”在我国刑事诉讼实务界是比较盛行的一种观点，认为我国刑事诉讼基本原则是公检法三机关“分工负责，相互配合，相互制约”关系，三机关、三阶段均是为了保证刑事诉讼活动的顺利进行，并无孰轻孰重之分。此种观点虽然是以我国刑事诉讼法为依据，但是却回避了由“谁”通过何种方式认定案件事实并最终决定被告人的命运问题。从一个完整的、理想的诉讼形态考察，侦查和审查起诉仅是控方为审判而进行的准备活动；在法庭审理过程中，控辩双方平等、理性对抗，由中立的第三方进行裁判，因此，决定被告人定罪量刑的应为审判程序，这是“审判中心主义”的基本要求。应当说，“充分发挥审判特别是庭审的作用，是确保案件处理质量和司法公正的重要环节”，“有利于促使办案人员增强责任意识，通过法庭审判的程序公正实现案件裁判的实体公正，有效防范冤假错案产生”。^②

毋庸讳言，在司法实践中，“侦查中心主义”现象仍然比较盛行。侦查在诉讼中处于中心地位外化为两个方面：一方面，侦查阶段收集的证据材料尤其是书面表现形式的材料（如证人证言、鉴定意见等）在审判中直接作为裁判的依据（关于此点，将在后文结合庭审方式进行阐述）；另一方面，不仅侦查活动围绕逮捕展开，而且一旦犯罪嫌疑人被检察机关批准或决定逮捕，就很难逃脱被起诉、定罪的命运，审查逮捕替代审判程序成为解决犯罪嫌疑人、被告人刑事责任的核心环节，逮捕异化为“定罪的预演、刑罚的预支，致使后继的审查起诉、法庭审理均遭架空”。^③此种现象，被称为“逮捕中心主义”。^④

在2012年《刑事诉讼法》修改前，不仅逮捕率居高不下，而且逮捕通常会导致起诉和定罪后果。1990—2009年，全国检察机关共批准逮捕、决定逮捕14579934

① 田口守一：《刑事诉讼法》，刘迪等译，北京：法律出版社，2000年，第25页。

② 习近平：《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》，《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，第58、59页。

③ 郭晶：《“逮捕实体化”之模式、危害及成因——“行政内控”与“诉讼制衡”之间的尖锐冲突》，《西部法律评论》2012年第6期。

④ 参见李昌盛：《走出“逮捕中心主义”》，《检察日报》2010年9月23日，第3版。

人,提起公诉 15550883 人,捕诉率为 93.76%。“仅就刑事犯罪案件来说,上述 20 年间共逮捕犯罪嫌疑人 14148048 人,提起公诉 14917109 人,捕诉率高达 94.84%。”^① 犯罪嫌疑人被起诉之后,几乎难以逃脱被定罪的命运,实践中宣告无罪的判决少之又少。2012 年《刑事诉讼法》修改后,根据对相关数据的考察,逮捕中心主义的现象并没有消失。2013 年 1—4 月,全国检察机关审查逮捕案件 219917 件 310173 人;批准逮捕和决定逮捕 183898 件 254262 人;捕后撤案 8 件,法院判无罪 7 人;捕后判处轻缓刑(包括管制、拘役、免于刑事处罚、单处罚金、徒刑缓刑) 50793 人,轻缓刑比例占逮捕总数的 19.98%。^② 上述数据没有直接提供捕后起诉的比例,地方检察机关的相关数据对此有所反映。如某直辖市 2013 年办理审查逮捕 15545 件 20275 人,捕后不起诉 276 人。^③ 某地级市检察机关 2013 年批准逮捕 1494 件 2074 人,提起公诉 1571 件 2324 人,仅有 1 人被宣告无罪。^④ 这些数据表明,犯罪嫌疑人一旦被逮捕,很难逃脱此后被起诉继而被判有罪的命运。

“逮捕中心主义”的弊端较为明显,主要表现在以下几个方面:

第一,“逮捕中心主义”以审查逮捕取代审判,混淆了侦查与审判职能。侦查阶段,逮捕的对象是犯罪嫌疑人。按照无罪推定原则,被追诉人在生效裁判确定之前应被视为无罪的人,对其适用强制措施的目的是为了保证诉讼活动顺利进行,防止其逃避诉讼活动或者继续危害社会,而不是对其进行定罪处罚。就此而言,“逮捕中心主义”以审查逮捕程序替代审判活动,混淆了二者的功能。

第二,“逮捕中心主义”违背诉讼认识规律。不同诉讼阶段办案人员认识案件事实所依据的材料不同,认识的程度与标准也有差异。审查逮捕一般发生在侦查阶段初期,检察人员对事实的认识往往依据侦查机关或部门单方面提供的证据材料;相应地,逮捕的证明标准是“有证据证明有犯罪事实”。而在审判阶段,法官要对案件事实进行全面核查和判断,听取控辩双方质证、辩论甚至是依职权调查,对被告人定罪的证明标准是“事实清楚,证据确实、充分”。就此而言,审查逮捕环节检察人员的认识不应也不可能等同于审判阶段法官对案件事实的认识和判断。

第三,“逮捕中心主义”剥夺了被告人的诉讼权利。被告人在法庭审理阶段依法享有辩护、参加法庭调查、法庭辩论、最后陈述等诉讼权利,并享有未经人民法院依法判决,不得被判定有罪及获得独立、公正审判等程序保障。法律之所以作此规定,旨在赋予辩方对抗控方的手段,以通过自身的诉讼行为影响法庭裁判形成过程

① 刘计划:《逮捕审查制度的中国模式及其改革》,《法学研究》2012 年第 2 期。

② 逮捕率同比下降 12.3%。数据参见《最高人民检察院关于 1 至 4 月全国检察机关侦查监督、公诉部门执行修改后刑诉法情况通报》(高检诉[2013]33 号)。

③ B 市人民检察院案件管理办公室制:《B 市检察机关业务基本情况表》(2013 年 1 月—11 月汇总地区分布)。

④ 此数据由 G 省 B 市检察机关提供。

及最后结果。然而,“逮捕中心主义”使得被追诉人的上述诉讼权利和保障徒有形式,审判程序沦为逮捕决定正确性的确认程序。

第四,“逮捕中心主义”扭曲了法检两机关之间的关系。权力分离和制衡为当代诉讼制度基石之一。然而,在“逮捕中心主义”下,法院对案件的裁判被逮捕决定“绑架”。一旦检察机关作出逮捕决定,为避免其遭受“负面评价”,法院裁判一般不仅会作出有罪判决,而且绝大多数量刑为实刑。审查批准逮捕在很大程度上代替法院对刑事案件作出终局裁判。此时,法院成为检察机关的“帮手”。最终结果是,审查逮捕成为诉讼的中心阶段,检察机关成为决定案件走向的核心机关。

逮捕和审判的功能、适用条件、标准等迥然有异,相关的诉讼行为方式也有很大区别。对此我国《刑事诉讼法》已有明确的界定和划分。那么,何种因素导致审查逮捕替代审判成为诉讼的核心程序呢?有学者认为主要有以下制度性原因:逮捕必要性要件的模糊和羁押替代措施的不完善;审前程序中司法权的缺席与被追诉人权利救济机制的匮乏;“流水作业”式的诉讼构造与独特的司法权运行机制。^① 2012年《刑事诉讼法》的修改,对上述问题作出了不同程度的回应。例如,修改后的法律细化了社会危险性要件,并初步构建了诉讼化的审查批捕程序。然而,修改后的刑事诉讼法,并未能有效制约“逮捕中心主义”。笔者认为,除前述原因之外,还有一些与诉讼制度层面并没有直接关系的制度或规则扭曲了逮捕功能,使得检察机关在逮捕时必须考虑能否起诉并能否被定罪,而且一旦在作出逮捕决定后,必然通过各种方式寻求起诉和定罪的结果。其中,《国家赔偿法》相关条款的理解、适用,以及检察机关的考核制度起了最为关键的作用。

首先,《国家赔偿法》相关规定及其“误读”。《国家赔偿法》第17条规定:“行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:……对公民采取逮捕措施后,决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的;……”从人权保障层面考量,对最终不被追究刑事责任而被逮捕的公民由国家给予赔偿,无疑是合理的。但是,符合法定条件但达不到起诉或定罪标准的逮捕并不一定就是“错误逮捕”。逮捕的适用标准和条件、适用的诉讼阶段与定罪完全不同,是否作出逮捕决定与案件是否被撤销、不起诉、判决宣告无罪并无必然关联。实践中下列现象并不鲜见:检察机关对犯罪嫌疑人在侦查阶段作出逮捕的决定完全符合法律规定,但是,此后收集的证据没有达到“犯罪事实清楚,证据确实、充分”的程度,或者审查起诉部门、审判机关认为没有达到此程度。因此,依据前述条文作出国家赔偿的案件,不一定是错案,甚至不一定是错误逮捕,将一部分合法逮捕划为“侵犯

^① 参见王彪:《刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析》,《中国刑事法杂志》2014年第2期。

人身权”的错误逮捕、错案是不合理的。这种以案件的后续处理结果为标准判断逮捕决定正确性的做法，成为“逮捕中心主义”的一大诱因。与此同时，由于国家赔偿的费用由地方承担，如果一个检察院有较多的国家赔偿案件，地方领导或者其他权力机构对检察机关的工作也可能产生质疑或者其他消极评价。

其次，检察机关不合理的案件评价标准与考核机制也促使形成“逮捕中心主义”。在检察机关内部，同样以案件的最终处理结果衡量逮捕质量。《人民检察院审查逮捕质量标准》第 26 条规定，“批准逮捕后，犯罪嫌疑人被依照刑事诉讼法第一百四十二条第二款决定不起诉或者被判处管制、拘役、单处附加刑或者免于刑事处罚的”，“属于办案质量有缺陷”。^①在检察系统考核制度中，如果一个案件作出逮捕决定但最终不起诉、宣判无罪，此案件将被纳入考评系统中质量不高的 C 类或者 D 类，^②该检察机关的侦查监督部门将要被处以“扣分”的消极评价。这种评价机制同样存在问题。随着证据的不断收集以及新情况的出现，在审查批准逮捕时犯罪嫌疑人有可能被判处有期徒刑以上刑罚的案件，检察机关有可能作出酌定不起诉决定，法院可能作出管制、拘役、单处附加刑或者免于刑事处罚的判决。另外，无论是检察官还是法官，对于同一个案件完全可能因为在法律许可的自由裁量权范围内或者对其中某个或某些证据的理解、采信不同，导致检察机关认为案件应该判处有期徒刑以上刑罚，而法官则认为应当判处管制、拘役等刑罚甚至是免除处罚。

在国家赔偿和考评体系的综合评价之下，检察机关在作出批准逮捕决定以后，往往要通过事先沟通、协调甚至不当施压等各种途径确保法院作出有罪判决。^③

综上，逮捕“绑架”审判，成为刑事诉讼纵向构造中的核心环节，与“庭审中心主义”背道而驰，不仅违反现行法律规定，也违背刑事诉讼认识规律，甚至可能导致案件处理错误呈现连锁反应。欲实现刑事庭审实质化，从纵向维度看，应当消除“逮捕中心主义”、切断审查逮捕与审判的联系，建立“庭审中心”的诉讼构造。

“建立健全科学合理、符合司法规律的办案绩效考评制度，不能片面追求破案率、批捕率、起诉率、定罪率等指标”。^④如前文所述，之所以审查逮捕异化为审判、逮捕“绑架”定罪甚至量刑，从制度层面分析，其直接原因就是存在不合理的考核制度。根据“理性经济人”假设理论，理性人不仅有很强的计算能力，能推算出每种选择的后果，而且能够使其选择的方案对自己最为有利。由于逮捕的三个条件，包括“有证据证明有犯罪事实”、“可能判处有期徒刑以上刑罚”和“社会危险性”

① 此处“刑事诉讼法”指的是 1996 年修改的《刑事诉讼法》。

② A 类为质量最高的评级，其他依次为 B、C、D 类。

③ 对于法院而言，促使其在作出裁判时“考虑”检察机关是否采取逮捕措施，甚至有时“听命于”检察机关的因素是多重的，包括传统观念、权力之间天然的亲和性以及检察机关作为法律监督机关的地位等。

④ 中央政法委《关于切实防止冤假错案的规定》第 14 条。

具有很大的自由裁量空间,检察机关及其承办者在逮捕与起诉、定罪结果相捆绑的考核制度下,作为理性经济人,在审查逮捕时不可能不考虑到案件与其自身的利害关系。在自由裁量权范围内以及模糊边界,甚至在不明显违法或者此种违法不易被发现的情形下,在理性经济人趋利避害原则的指引下,检察机关在审查逮捕时以及后续诉讼行为中不可能不考虑起诉和定罪甚至量刑结果。要扭转此种局面,应当在“建立健全科学合理、符合司法规律的办案绩效考评制度”方针指引下,对国家赔偿制度和现有考评机制进行改革与完善。

与审查逮捕相关考评体系中,至少应考虑以下因素:首先,修改《国家赔偿法》第17条第2项,按照国际刑事司法准则的相关要求,增设侵犯人身自由权的赔偿,并与错案赔偿并列。同时,将错案赔偿的标准定为“原审为有罪判决,当事人已经服刑,经过再审改判无罪”。^①其次,在现行《国家赔偿法》规定下,符合逮捕条件但最终作出国家赔偿的案件,不再作为错案赔偿,不纳入侦查监督部门考评体系。再次,程序具有刚性,“程序正义是看得见的正义”,其违法亦是显性的,因此应当将审查逮捕程序中的违法因素(错误逮捕)作为考评体系的重要指标。最后,将故意或者重大过失的实体处理行为作为考核指标。除这两种办案机关或办案人员有明显过错且能够被认定的情形外,不应将实体的处理结果作为逮捕的考核标准。

三、庭审方式:从“卷宗中心主义”到言词审理

在审判程序中,“卷宗中心主义”的裁判模式是造成刑事庭审虚置的首要因素。所谓“卷宗中心主义”的裁判模式,是指“刑事法官普遍通过阅读检察机关移送的案卷笔录来展开庭前准备活动,对于证人证言、被害人陈述、被告人供述等言词证据,普遍通过宣读案卷笔录的方式进行法庭调查,法院在判决书中甚至普遍援引侦查人员所制作的案卷笔录,并将其作为裁判的基础”。^②

“卷宗中心主义”肇始于1979年《刑事诉讼法》。该法规定,检察院提起公诉时须向法院移送全案卷宗材料,法院对提起公诉的案件进行实质审查,只有达到“犯罪事实清楚,证据确实、充分”标准,才能开庭审判。同时,主持庭前实质审查的法官一般就是庭审法官。由于“审判员在开庭前对案件已形成较固定的认识,对如何判决也多有了初步决定,并请示庭长、院长;对一些重大疑难案件,则往往开庭前已经审委会讨论甚或请示上级法院。案件还未开庭审理,审判员对案件的定性、量刑已成定论。开庭成了走过场。被告人、辩护人提出的相反意见很难受到重视”。^③

① 杨宇冠:《我国刑事赔偿制度之改革》,《法学研究》2004年第1期。

② 陈瑞华:《刑事诉讼的中国模式》,北京:北京大学出版社,2010年,第161页。

③ 王尚新:《刑事诉讼法修改的若干问题》,《法学研究》1994年第5期。

为防止法官庭前预断,1996年《刑事诉讼法》取消全案卷宗移送制度,确立了主要证据“复印件”移送制度;改庭前实质审查为形式审查,取消法官庭前调查,并将开庭审判的条件修改为“起诉书中明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的”。从理论上分析,前述改革有助于遏制庭前预断,但是,实践表明不仅未消除“卷宗中心主义”现象,反而产生了新的问题。首先,法官庭前预断并未得到预防。前述修改虽然限制了检察机关移送的案卷材料范围,但法官仍能接触到经过控方精心挑选的证明被告人有罪的案卷材料,难以避免形成被告人有罪的心证。其次,庭后移送案卷制度使得庭审流于形式。为应对卷宗移送制度改革给法庭审判带来的挑战,相关解释性文件不仅明确了“主要证据”的范围,还规定了庭后卷宗移送制度。^①庭后移送全案卷宗,再一次导致庭审流于形式。由于无法适应颇具“当事人主义”色彩的裁判者角色,同时由于检察机关多采取选择式、摘要式、合并概括式的举证方式而无法把握案件事实,更由于“控方移送的案卷材料不仅被推定为天然可采、而且具有较辩方证据更高的证明力”,^②法官最终把所有的希望都寄托到庭后移送的案卷上,通过庭后仔细研读控方案卷进而作出判决,而在一定程度上“放弃”庭审。再次,辩护人的阅卷权被剥夺。根据1996年《刑事诉讼法》第36条,法院受理案件后,辩护律师阅卷的范围只限于检察机关向法院移送的主要证据的照片或复印件、证据目录和证人名单。而且,辩护律师到检察机关阅卷根本得不到准许。辩护律师无法全面了解、掌握控方的证据材料,也就无法展开充分的辩护。辩护律师无从进行充分有效的辩护,也进一步加剧了庭审形式化,放纵了“卷宗中心主义”的泛滥。

为消除“卷宗中心主义”弊害,强化直接言词审理,提高刑事庭审实质化的程度,2012年《刑事诉讼法》作了进一步改革,主要包含以下内容:回归“全案卷宗移送制度”,要求检察机关起诉时将“案卷材料、证据”移送法院;修改开庭审判条件,“对于起诉书中明确指控犯罪事实的,应当决定开庭审判”;完善证人出庭作

① 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会于1998年1月19日颁布的《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第42条规定,“人民检察院对于在法庭上出示、宣读、播放的证据材料,应当当庭移交人民法院,确实无法当庭移交的,应当在休庭三日内移交。对于在法庭上出示、宣读、播放未到庭证人的证言的,如果该证人提供过不同的证言,人民检察院应当将该证人的全部证言在休庭后三日内移交”。

② 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第15条后段规定,“证人在法庭上的证言与其庭前证言相互矛盾,如果证人当庭能够对其翻证作出合理解释,并有相关证据印证的,应当采信庭审证言”。可见,证人如推翻证言并想得到法庭的支持,必须作出合理解释,并有证据支持;从反面可推知,一般情形下,以庭前证言为准。

证制度,确立强制证人出庭作证制度,并明确证人、鉴定人应当出庭作证而不出庭的后果,等等。然而,无论是从立法层面抑或是司法解释的角度考察,法律的相关规定与以直接言词为核心的实质化庭审方式仍相去甚远。从立法层面考察,至少存在以下立法冲突和缺陷:

第一,《刑事诉讼法》第59条与第190条冲突。《刑事诉讼法》第59条对证人出庭作证作了强制性规定:“证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后,才能作为定案的根据。”所谓质证,是指在庭审过程中控辩双方在裁判者的主持下,采用询问、质疑、辩驳、核实等方式对证据的证明力以及证据能力等进行质辩的诉讼活动。对于证人证言的质证方式是交叉询问,即在主询问之后,由对方进行盘诘性询问,通过此种方式可以知晓证人证言的真实性或者在何种语境下作证。就此而言,该规定具有合理性。但是,第190条又规定,“公诉人、辩护人应当向法庭出示物证,让当事人辨认,对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书,应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见”。显然,此处“听取意见”与上述“质证”并非同一概念。其实,该冲突在1996年《刑事诉讼法》中即已存在,《刑事诉讼法》再次修改时并未予以重视。“正是这一立法缺陷,为刑事审判实践中证人不出庭作证打开了方便之门”。^①

第二,证人、鉴定人应当出庭的条件过于严苛,而且并未明确证人不出庭的程序性后果。《刑事诉讼法》第187条第1款规定,“公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议,且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响,人民法院认为证人有必要出庭作证的,证人应当出庭作证”。按照此规定,对于关键性证人是否出庭,即使控辩双方对其证言有异议,仍然取决于法院的主观认识。鉴定人出庭的条件与上述基本相同,“公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议,人民法院认为鉴定人有必要出庭作证的,鉴定人应当出庭”。此外,《刑事诉讼法》第188条仅规定对无正当理由拒绝出庭或出庭后拒绝作证的证人训诫、拘留等实体性制裁,并未明确该证人庭前所作书面证言的效力。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《解释》)第78条第3款规定:“经人民法院通知,证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证,法庭对其证言的真实性无法确认的,该证人证言不得作为定案的根据。”据此,即使符合上述条件的证人没有出庭,其证言并不是必然不能作为定案根据。

第三,拒绝出庭作证制度加剧庭审形式化。《刑事诉讼法》第188条规定“经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但被告人的配偶、父母、子女除外”。近亲属作证豁免特权的本质是对人性的认同和人伦的

① 陈光中、陈学权:《中国刑事证人出庭作证制度的改革》,《中国法律》2007年第5期。

尊重。但是，此规定确立的规则与近亲属作证特权制度至少在效果上相去甚远。因为此规定仅赋予了三类近亲属强制出庭的豁免权，而非“拒绝作证特权”。一旦知悉案件情况，其仍负有作证义务。三类特殊主体既负有作证义务，又无需出庭（自愿出庭者例外），其于庭前作证之证言笔录必然出现在法庭审理当中，法院依靠控方卷宗的审理方式得以正当化。

第四，证人保护及经济补偿制度不完善。在《刑事诉讼法》修改前，有学者将缺乏证人保护和合理的经济补偿制度视为司法实践中证人出庭难的两个重要因素。^①为解决该问题，《刑事诉讼法》第 62 条、第 63 条增加了特定案件中证人、被害人、鉴定人及其近亲属的保护措施及证人出庭作证经济补偿的规定。应当说这些规定对于促进证人出庭作证具有积极作用。然而，上述两个条文尚存在以下问题：首先，第 62 条将证人保护的主体规定为人民法院、人民检察院和侦查机关，但是并未注意到法院和检察院实际上并没有足够能力实施保护证人的现实。“在司法实践中，法院一般只负责证人进入法庭以后的人身安全，至于证人离开法院、甚至在法院门口，遭受被告人方人身攻击，法院一般也无能为力，只能求助于公安机关。”^②其次，第 62 条将证人保护的案件范围限制于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，导致其他类型的案件中意欲作证的证人面临人身安全等威胁时缺乏保护。再次，第 63 条规定，“证人因履行作证义务而支出的交通、住宿、就餐等费用，应当给予补偿……有工作单位的证人作证，所在单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇”。然而，刑事案件中的证人，并非均有工作单位，还存在大量的自由职业者、农民等。他们出庭作证所产生的误工费用理应得到相应的补偿。但是，法律和相关解释对此未予以明确。正是因为证人保护与经济补偿等相关规定自身存在的疏漏和缺失，证人保护和经济补偿制度的功能发挥有限。

除上述立法层面外，相关司法解释进一步强化了“卷宗中心主义”，主要表现在以下几个方面：

第一，最高人民检察院《刑事诉讼规则（试行）》（以下简称《规则》）第 441 条以司法解释的形式确认了未出庭证人的证言效力。如上述，《刑事诉讼法》第 187 条对未出庭证人的证言效力并未予以明确。但《规则》对此进行了“立法式”解释，“对于经人民法院通知而未到庭的证人或者出庭后拒绝作证的证人的证言笔录，公诉人应当当庭宣读”。如此一来，经过法院通知而拒绝出庭或拒绝作证的证人之书面证言，不但没有丧失其证据可采性，反而通过公诉人的宣读呈现于法庭并获得合法性，成为定案的根据。

第二，司法解释新增证据种类。根据《刑事诉讼法》，侦查人员出庭作证有两种

① 参见胡云腾：《证人出庭作证难及其解决思路》，《环球法律评论》2006 年第 5 期。

② 陈光中主编：《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉修改条文释义与点评》，第 88—89 页。

情形：一种是人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证；一种是在非法证据排除程序中，现有证据材料不能证明证据收集合法性的，经人民法院通知，有关侦查人员出庭说明情况。对于第一种情形，法院通知人民警察出庭作证，适用通知证人的规定，将有可能出现上述第一个方面述及的问题。对于第二种情形，虽然“经人民法院通知，有关人员应当出庭”，但是法律并没有规定不出庭的后果。然而，《解释》第101条第2款规定，“公诉人提交的取证过程的说明材料，应当经有关侦查人员签名，并加盖公章”。这就意味着侦查人员可以通过提供经签名的说明材料来替代出庭作证。《刑事诉讼法》并未规定“说明材料”这一证据种类，但是在司法实践中，该类材料却发挥着重要作用，成为证明侦查行为合法性的证据。

第三，《解释》承继庭后卷宗移送制度。《刑事诉讼法》之所以改革卷宗移送方式，将庭前审查由实质审查改为程序审查，即是为了解决“复印件主义”下辩护律师阅卷权被限制的弊端，意在保障辩护律师阅卷权的同时，切断控方卷宗与审判程序之间的联系，确保法官心证建立在法庭审理之上，并且在尽可能的范围内，由法庭当庭作出判决。但《解释》第219条规定，“当庭出示的证据，尚未移送人民法院的，应当在质证后移交法庭”。这就容易走庭后移送卷宗的老路：一些法官不重视庭审，而重视庭后阅卷，并在此基础上作出判决。另外，《刑事诉讼法》并未明确区分庭前审查与法庭审判的法官，司法实践中二者为同一主体，庭前预断的弊病并未铲除。

在此背景下，证人、鉴定人出庭的比例不可能提高。实践中的数据印证了此结论。如某地方法院2013年共审结411件刑事案件，有证人证言的案件287件，审判阶段证人出庭的案件为3件，占全部案件的0.7%。^①据浙江省司法厅统计，2013年该省办理涉及诉讼的司法鉴定36832件，鉴定人出庭作证只有167次，出庭率仅为0.45%。^②这些地方数据也在一定程度上反映了全国证人、鉴定人的出庭现状。在修改后《刑事诉讼法》实施后的数月中，全国范围内证人出庭比例为0.12%，鉴定人出庭比例为0.04%。^③相关调查报告显示，“证人出庭率不因强制作证制度而上升，强制作证在实践中大打折扣”，“证人出庭作证：不容乐观”。^④笔者认为，从审理方式的角度考

① 田源、杨继伟：《新刑诉法实施后证人出庭率低的原因分析》，2014年4月29日，<http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1285118.shtml>，2014年11月22日。

② 余世裕等：《鉴定人出庭作证制度实施现状及完善——以浙江省为视角》，《中国司法鉴定》2014年第5期。

③ 参见《最高人民法院人民检察院关于1至4月全国检察机关侦查监督、公诉部门执行修改后刑法情况通报》（高检诉〔2013〕33号）。

④ 参见北京市尚权律师事务所：《新刑诉法实施状况调研报告（2013年度）》。该调研报告认为问题主要表现在：“证人出庭的强制性明显不足。”根据调研结果，55.3%的受调查者认为，“大多数案件法院虽同意证人出庭，但不使用强制力作为后盾，证人是否前来凭其自愿”；23.2%的受调查者认为，“法院视证人与案件事实的关联性大小而决定

察,我国欲实现庭审实质化,应在废除“卷宗中心主义”的基础上实现直接言词原则。

直接言词原则,是指裁判者亲自听取控辩双方、证人及其他诉讼参与人的当庭口头陈述和法庭辩论,在此基础上形成对案件的认识并据此对案件作出相应的裁判。它包含直接原则和言词原则。直接原则,又称直接审理原则,该原则要求案件的裁判者只能以亲自在法庭上直接获取的证据材料作为裁判之基础。言词原则,又称言词审理原则,要求当事人等在法庭上须用言词形式举证、质证和辩论。我国刑事诉讼法虽然对此原则有所体现,但是并没有完全确立该原则。为实现直接言词原则,落实言词审理方式,需要从以下几个方面入手:

第一,明确庭前审查与法庭审判主体的二元化。在《刑事诉讼法》恢复全案卷宗移送制度、实行庭前程序审查的前提下,应当进一步明确庭前审查法官与庭审法官的二元化,庭前审查法官负责庭前会议的召集、主持。同时,应当明确控方卷宗的作用:一方面是供法院审查是否符合开庭审判条件,另一方面是保障辩护律师在开庭审判之前,能查阅、复制、摘抄全案证据材料,为实质性的有效辩护提供资料来源。控方卷宗应由庭前审查法官,而非庭审法官掌握。法院裁判应当建立在经质证、认证的证据基础之上,即使无法当庭作出判决,法庭裁判也只能建立在庭审记录,而非庭后阅卷的基础上。同时,应当废除庭后移送证据材料的规定。如果有新的证据材料出现,应当恢复法庭调查。

第二,进一步完善证人应当出庭作证的条件。证人出庭作证,无论对于查清案情从而实现实体公正,还是保障被告人的对质权进而实现程序公正,都有重要意义。当然,要求证人出庭作证,并不意味着所有证人都应当出庭,这样既无可能,也无必要。其实,修改后的《刑事诉讼法》亦采取了关键证人出庭的立场——只不过关键证人出庭的条件过于严苛而已。基于此,笔者认为,在近期再次修改立法不现实的背景下,应当通过立法解释对《刑事诉讼法》第 187 条规定的证人出庭作证条件作出修改,即证人具备下列情形之一的应当出庭作证:公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议,且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响,或者人民法院认为证人有必要出庭作证的。

第三,明确相关证据规则。中央政法委《关于切实防止冤假错案的规定》第 6 条要求,“坚持证据裁判原则。依法应当出庭的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证,法庭对其证言真实性无法确认的,该证人证言不得作为定案的根据。证据未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的,不得作为定案的根据”。首先,应明确应当出庭作证而未出庭的证人证言不得作为定案的根据。如前所

是否强制传唤证人”;只有 15.4% 的受调查者认为,“法院强制证人出庭制度贯彻正常”。(http://www.sqxb.cn/content/details16_1644.html, 2014 年 3 月 13 日)

述,《刑事诉讼法》第188条未明确关键证人不出庭时庭前证言笔录的效力,但是,《刑事诉讼法》第166条及《解释》、《规则》变相确认了该证言笔录的证据能力和证明力。因此,如欲实现直接言词原则,保障关键证人出庭作证制度得以贯彻,应明确其程序性后果,即证言笔录不具有证据能力,不能在法庭上出示,更不能作为定案的根据。其次,全国人大常委会应通过立法解释明确,对于父母、配偶、子女等不能强制出庭作证;但是,其证言不利于被告人的,如果被告人要求,应出庭作证。因为法律规定不能强制近亲属出庭作证的初衷,是基于人伦和保护家庭关系的稳定等,但是,如果近亲属作出不利于被告人证言的情形下,这种价值保护的前提就已经不存在。此时从保护被告人的质证权出发,应规定其有权与亲属进行对质。当然,作长久计,法律应当建立特定范围内的亲属作证豁免制度,即特定范围内的近亲属没有作证的义务——除非在有利于被告人情形下。再次,应明确警察不出庭作证的程序性后果。按照法律规定,警察无论是对执行职务时目击的犯罪情况,还是对证据收集的合法性加以证明的场合,均有出庭作证的义务。从证据的法定种类考量,公安机关的“说明材料”并不属于八种法定证据种类中的任何一种;从程序角度看,“说明材料”也无法接受辩方的质证。基于此,对于侦查人员应出庭作证而不出庭的,相关“说明材料”没有证据能力,其收集的材料不能作为定案的根据。

第四,完善证人保护与经济补偿制度。“没有一种法律制度有正当理由能强迫证人作证,而在发现证人作证受到侵害时又拒绝给予援助。”^①为降低关键证人出庭的难度,有必要对相关制度作进一步补充和完善:在《刑事诉讼法》明确公、检、法等机关为证人保护措施的决定主体的基础上,由公安机关统一负责运用《刑事诉讼法》规定的措施对证人加以保护,防止因为决定机关无足够的人员配置和能力而导致证人保护落空的现象出现。同时,明确将证人因作证产生的误工费用纳入经济补偿范围,可以参照国家上年度职工日平均工资设置具体的标准。

综上,只有法律明确庭前审查法官和审判法官二元化、合理设置关键证人(鉴定人、侦查人员)出庭的条件及不出庭的后果、完善证人出庭作证的保护机制和经济补偿制度,以确保关键证人(鉴定人、侦查人员)出庭接受质证、询问,才能消除卷宗中心主义的弊端,确保法庭审判的实质化。

四、庭前会议:从实质审查到程序审查

庭前会议是2012年《刑事诉讼法》新增加的一项制度。《刑事诉讼法》第182条第2款规定:“在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听

^① 丹宁:《法律的正当程序》,李克强等译,北京:法律出版社,1999年,第25页。

取意见。”从立法目的看,“这一程序设计允许法官于开庭前,在控辩双方同时参与下,对案件的程序性问题集中听取意见。这样规定有利于确定庭审重点,便于法官把握庭审重点,有助于提高庭审效率,保证庭审质量。”^①由此可见,庭前会议的制度定位是程序性审查。然而,在司法实践中,庭前会议呈现出明显的“实体化”倾向,并僭越法定位,在一定程度上有取代正式庭审的征兆。突出表现在,庭前会议处理事项的范围并不仅限于管辖、回避等程序性问题,还包括与定罪量刑相关的事实和证据等广泛的实体性问题。而主持庭前会议的法官往往是合议庭成员,他们在庭前会议中对上述问题的理解和认识将不可避免地形成“预断”,对后续的法庭审理产生重要影响。就此而言,法庭审理的核心——定罪量刑事实上已被前置于庭前会议之中,庭前会议有虚置甚至取代法庭审理之嫌。

从法律规范的层面考察,造成庭前会议“实体化”、法庭审理被虚置主要是由法典相关规定不足和相关司法解释越权所致。

第一,实体性问题被纳入庭前会议处理事项导致庭前会议“实体化”。对于庭前会议处理事项的范围,《刑事诉讼法》第182条第2款进行了简要列举,规定为“回避、出庭证人员名单、非法证据排除等”。此处“等”字表明,庭前会议处理的问题包含但不限于上述事项。对此,相关司法解释进行了必要补充,与此同时,也超越法律将大量实体性问题纳入其中。如《规则》第431条第1款规定,公诉人可以对“辩护人提供的无罪证据”提出和交换意见。该条第3款还规定,“公诉人通过参加庭前会议,了解案件事实、证据和法律适用的争议和不同意见”。另外,根据《解释》第184条第3款,在庭前会议中,“被害人或者其法定代理人、近亲属提起附带民事诉讼的,可以调解”。然而,在正式开庭审判之前,先行调解民事诉讼将很可能使法官产生庭前预断。一旦被告人接受调解,就会对审判人员造成被告人很有可能存在犯罪行为的暗示。

第二,庭前会议召集人兼任庭审法官使法庭审理虚置。《刑事诉讼法》第182条第2款的规定,庭前会议由审判人员召集。若将第182条作为一个整体来解读,此处“审判人员”似乎应为合议庭组成人员,因为该条第1款即规定“人民法院决定开庭审判之后,应当确定合议庭的组成人员……”。这种解读也得到了法律起草机构的认同。全国人大法工委解释该款时,认为“本款规定的审判人员可以是合议庭组成人员”。^②若照此理解,再结合前文所述之有关定罪量刑的实体问题已被纳入庭前会议处理范围的情况来看,庭前“预断”将不可避免,其后果是法庭审理在很大程度上沦为一种形式。另外,即使某些程序性事项的处理也会产生预断的问题,如非

① 全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《〈关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定〉条文说明、立法理由及相关规定》,北京:北京大学出版社,2012年,第215页。

② 郎胜主编:《中华人民共和国刑事诉讼法释义》,北京:法律出版社,2012年,第395页。

法证据的排除。尽管庭前会议对非法证据的审查仅限于取证过程的合法性,但审判人员会因此而接触和了解非法证据的内容。无论该证据最后是否因为程序违法而被排除,它(们)实际上都已经影响了法官的心证,而且考虑到非法证据往往是证明被告人有罪或罪重的控诉证据,该心证往往不利于被告人。

应当说,《刑事诉讼法》仅用一个条文对庭前会议制度进行规定,确实存在语言含混、内容粗疏等不足,需要解读和诠释,由司法解释对相关事项予以明确和细化有其必要性。从法律解释学的原理看,在解释法条时应当严格遵守合法性原则、合目的性原则、权力谦抑原则、权利保护原则的要求。^①唯有如此,解释才有可能秉承立法原意,从而实现立法初衷。就庭前会议而言,从性质和地位上看,其属于庭前准备程序的组成部分,而非法庭审理的一个环节。其设置的目的是通过对相关程序性事项的处理,以“提高庭审效率”、“保证庭审质量”。换言之,庭前会议“只是正式庭审前的一个准备阶段,不是正式庭审更不能取代庭审,涉及定罪量刑等实质性问题均应在正式庭审中审理”。^②为了实现上述立法意图,切实发挥庭前会议的应有功能,当前应当扭转庭前会议“实体化”的倾向,真正实现刑事庭审实质化。具体可从以下几个方面入手:

第一,将庭前会议处理事项严格限定为程序性事项,使庭前会议功能回归立法初衷。如前所述,对于庭前会议处理事项的范围,《刑事诉讼法》第182条第2款确定为“回避、出庭证人名单、非法证据排除等”,此处的“等”字表明,除了条文中明确列举的三类事项,还可以包含其他事项。但究竟包含哪些事项,享有司法解释权的机关在界定时必须遵循“合法性原则”,即“解释不能超越法律”。如上述,由于庭前会议只是庭前准备程序的一部分,而非法庭审理的必经环节,因此,其处理的事项只能限于相关程序性事项,而不应涉及实体性问题的处理,证据的证明力、案件事实的认定以及法律适用等与定罪量刑直接相关的问题只能在庭审环节通过法庭审理的方式加以裁决。据此,相关司法机关应当对《规则》第431条以及《解释》第184条第3款作出相应修改,将相关实体性事项从庭前会议处理事项中剔除。

第二,将召集庭前会议的审判人员与参与法庭审理的法官相分离,防止庭前预断。对于召集庭前会议的审判人员,立法或相关司法解释应当作出禁止性规定,明确其不得在后续的法庭审理阶段担任合议庭成员,对案件进行审判。只有将召集庭前会议的审判人员排除在合议庭之外,才可以有效防止其将庭前会议中形成的对相关实体问题或程序事项的认识和判断带到庭审,影响其裁决,甚至直接作为裁判的基础。而相应地,审理案件的合议庭成员因为没有事先参加庭前会议,不可能借此

① 参见汪海燕:《刑事诉讼法解释论纲》,《清华法学》2013年第6期。

② 陈光中主编:《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉修改条文释义与点评》,第261页。

对案件中的实体和程序问题形成先入之见，因此必须以庭审为基础形成自己的认识和裁判，从而促进庭审实质化。

此外，为了促进实质化庭审的高效运行，还应当明确庭前会议的效力问题。《刑事诉讼法》仅规定庭前会议可以对相关问题“了解情况、听取意见”，未明确之后的具体处理方式。《解释》除了明确庭前会议情况应当制作笔录以外，未对此予以补充解释，也未明确庭前会议笔录的效力。正因如此，在司法实践中，相关诉讼主体对庭前会议解决的事项在庭审过程中再次提出的现象并不鲜见。申请回避、变更管辖等程序性事项亦无法在庭前会议阶段得到彻底解决，进而“很有可能出现在正式的法庭审理过程之中，法官一旦当庭予以受理，就势必会中止庭审过程，影响审判的集中进行”。^①为此，法律应明确赋予庭前会议对争议事项处理的效力，以保证此后的庭审实质化高效实现。

五、庭审内容：从定罪中心到定罪量刑并重

被告人刑事责任的认定包括两个部分：定罪和量刑。与之对应，庭审实质化也应包括定罪审理实质化和量刑审理实质化。在我国，量刑实质化的重要性并不亚于定罪实质化。有学者认为，“中国刑事司法的经验显示，绝大多数案件的被告人都作出了有罪供述，控辩双方在这些案件中几乎对被告人是否构成犯罪没有明显的争议”；“从普遍意义上看，中国刑事审判的核心问题是量刑问题，而不是定罪问题”。^②

量刑成为法庭审理的重心，对我国传统的以定罪为中心的定罪量刑一体化的程序模式提出了挑战。在 2012 年《刑事诉讼法》修改之前，法庭审理实行“定罪量刑一体化”模式。在这种模式中，法庭审理的重心在于被告人是否构成犯罪，量刑程序依附于定罪程序，法庭并不单独就量刑问题举证、质证和辩论。很明显，此种审理模式仅实现了对定罪部分实质化审理，而量刑程序由于被定罪程序湮灭并未实现实质化，这不仅可能导致实体上量刑不公，也剥夺了当事人在量刑事项上的举证、质证等程序性权利。同时，定罪、量刑证据的混合使用，也易使法官形成预断。量刑证据以及相关材料与定罪的证据材料并不完全相同，一些如前科、累犯等不利于被告人的量刑材料或信息出现在定罪程序中可能使裁判者先入为主，容易促使其形成被告人有罪的心证。另外，在被告方作无罪辩护的情形下，“定罪量刑一体化”模式将会使其陷入两难境地。“如果不做从轻量刑的辩护，辩护律师就无法促使法庭注意那些有利于被告人的量刑情节；如果在法庭辩论中提出从轻量刑意见，又势必与

① 陈瑞华：《论彻底的事实审：重构我国刑事第一审程序的一种理论思路》，《中外法学》2013 年第 3 期。

② 陈瑞华：《刑事诉讼的前沿问题》，北京：中国人民大学出版社，2013 年，第 328 页。

前面所作的无罪辩护意见相悖,以致大大削弱无罪辩护的效果。”^①

为消除上述弊端,在2012年《刑事诉讼法》修改之前,我国相关司法机关就进行了量刑程序改革。在此背景下,“相对独立的量刑模式”得以确立,其主要包括:第一,法庭应当将量刑纳入法定审理程序,在法庭调查、法庭辩论等阶段,应当保障量刑活动的相对独立性。在法庭调查阶段,可以先就定罪事实和证据进行法庭调查,再相对集中地就量刑事实和证据进行法庭调查。在辩论阶段,可分别就定罪和量刑问题展开辩论,增强量刑辩论的针对性。第二,明确了检察机关的量刑建议权以及当事人、辩护人、诉讼代理人提出量刑意见的权利。人民法院应当允许并组织公诉人、当事人、辩护人和诉讼代理人就量刑问题发表量刑意见,并注意听取他们的意见。第三,要求法官在刑事裁判文书中,应当说明量刑理由,增强量刑的公开性和透明度。^②

然而,2012年《刑事诉讼法》并没有明确规定“相对独立的量刑模式”。《刑事诉讼法》第193条第1款规定“法庭审理过程中,对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论”。应当说,该条虽然强调对与“量刑有关事实、证据”的调查和辩论,但对于量刑程序与定罪程序是“混合一体式”,还是相对独立抑或是完全独立,则语焉不详。而司法解释则确立了“相对独立的量刑模式”,在一定程度上弥补了此缺憾。《解释》规定,法庭审理过程中,应当对与量刑有关的事实、证据进行调查;对被告人认罪的案件,法庭调查和法庭辩论主要围绕量刑和其他有争议的问题进行;对被告人不认罪或者辩护人作无罪辩护的案件,法庭调查应当在查明定罪事实的基础上,查明有关量刑事实,而法庭辩论则先辩论定罪问题,后辩论量刑问题。^③《规则》第399条规定,人民检察院可以提出量刑建议。

在“相对独立的量刑模式”之下,量刑成为与定罪并列的法庭审判事项,量刑程序的地位得以彰显,量刑依附于定罪的问题得以解决。但该模式仍然存在问题,与庭审量刑实质化还有距离。

首先,在相对独立的量刑程序中,辩方深陷“两难境地”的问题未能得到解决。《解释》区分了被告人认罪与被告人不认罪或辩护律师作无罪辩护两种情形。在被告人认罪的案件中,法庭调查和法庭辩论主要围绕量刑问题进行,故不存在问题。在被告人不认罪或辩护律师作无罪辩护的案件中,该问题则较为明显。在相对独立的量刑程序中,定罪和量刑的裁判并未彻底分离,量刑辩护是在定罪问题未得以确定的情形下展开的,一旦被告人及其辩护人放弃参加量刑辩护,有可能在被告人被定

① 陈瑞华:《论量刑程序的独立性——一种以量刑控制为中心的程序理论》,《中国法学》2009年第1期。

② 参见《严格程序 规范量刑 确保公正——最高人民法院刑三庭负责人答记者问》,《人民法院报》2009年6月1日,第2版。

③ 参见《解释》第225、227、228、231条。

罪的情形下丧失量刑辩护的机会。在这种压力之下,辩护方往往采取一方面作无罪辩护,一方面在假设被告人被定罪的基础上,提出被告人应当或可以减轻、从轻的量刑辩护策略。而这种策略无疑使无罪辩护的效果削弱,甚至推翻己方的无罪辩护意见。

更为严重的是,在法庭调查中对量刑证据进行调查,其中一些证据可能使裁判者形成先入为主的有罪心证。因为,定罪与量刑的基础不同,定罪证据与量刑证据或其他材料亦不同。定罪问题,包括罪与非罪,此罪与彼罪,取决于某个行为是否符合犯罪构成要件,关注的是事实,体现刑罚适用的统一性和刚性。而量刑是在定罪的基础上,确定行为人应受何种处罚。这种处罚的依据包括三个部分,第一类是符合特定犯罪构成要件的事实,包括各种犯罪形态,如犯罪预备、中止、未遂;第二类是与犯罪事实无关的法定量刑情节,如自首、立功、累犯、未成年、聋哑等情形;第三类是与犯罪事实无关的酌定量刑情节,这些情节往往体现为行为人个体的一些情形,在很大程度上取决于裁判者的自由裁量,如前科(不包括累犯)、被告人的品行、被告人尤其是青少年被告人的家庭背景甚至社会原因、被告人悔罪的态度、与被害人达成的谅解等。因此,量刑与定罪有很大的不同,它不仅关注相关事实,而且亦重视行为人的个体情况,在很大程度上体现了刑罚的差异化 and 个性化。在相对独立的量刑程序中,量刑问题的调查是在查明定罪事实的基础上进行的。虽然《规则》第 435 条第 2 款规定,“定罪证据和量刑证据需要分开的,应当分别出示”,但是这种“分别出示”是在同一阶段内进行的。在事实调查环节,量刑证据不仅在定罪证据之后出现,还有可能首先被展现在法庭上。按照我国起诉书的格式,正文的第一部分载明被告人情况时,就要写明被告人以前受过刑事处罚的情形;即使被告人没有前科,但是如果有控方掌握的其他不利于被告人量刑的材料,如以前一般的违法记录,可能也会在法庭调查阶段的量刑证据材料调查部分展现。而一旦控方提供的不利于被告人的量刑证据被展示,法官在对案件事实的认定过程中,就很难将其与定罪问题完全隔离开,且自由心证不受任何影响。更有可能的情形是,法官将有罪证据与不利于被告人的量刑证据结合起来,以增强其内心确信。在此种情况下,被告方作无罪辩护,将被视为不成立,甚至是“认罪态度不好”;被告方一旦作量刑辩护,则被视为对法官内心确信的补强。不仅不能将这些量刑材料与定罪材料完全分开,控方出示的定罪材料和这种不利于被告人量刑材料混合的结果可能促使裁判者形成被告人有罪的心证。

因此,为实现定罪和量刑两个方面的庭审实质化,保障辩护方的量刑辩护权利,我国法律(包括司法解释)应当对我国量刑模式作出进一步的改革,即在程序分流的基础上,对于被告人不认罪的案件,实行独立的量刑程序。

第一,在被告人认罪的案件中,设立以量刑为主的审理模式。按照《解释》的思路,以被告人认罪与否、辩护人是否作无罪辩护为标准,对刑事案件进行分流,

适用不同的审判程序。对于被告人认罪的案件,保持现有模式不变,法庭审理主要围绕量刑和其他争议问题进行。对于被告人认罪,且符合简易程序、轻微案件速决程序适用条件的案件,法庭审理主要围绕量刑程序和其他争议问题展开的同时,可以进一步简化审理程序,提高办案效率,以便节约更多的司法资源用于办理被告人不认罪或辩护律师作无罪辩护的案件。

第二,在被告人不认罪或辩护律师作无罪辩护的案件中,确立完全独立的量刑程序。在此模式中,定罪与量刑程序完全分离,只有在确定被告人有罪之后,才能进行量刑程序。应当说,此种程序既能够避免辩护陷入上述两难之境地,也可以防止量刑材料对定罪的影响。但是,完全独立的量刑程序也有其不可避免的弊端,即由于程序繁琐导致诉讼效率低下。然而,此种顾虑不应成为抵制实行完全独立的量刑程序的理由。从司法实践的角度考察,随着公诉案件当事人和解程序等庭审替代程序的发展和完善,一些案件在审判前程序中即被分流,而进入法庭审判的案件也以被告人认罪居多。被告人不认罪或作无罪辩护的案件只占极小的比例,即使实现完全独立的量刑程序也不会为法院增加无法承受的负担。

六、结 语

从刑事诉讼法的发展趋势看,刑事审判程序正面临着来自审前案件分流、庭审辩诉交易等审判替代措施的挑战。这种挑战带来的直接性后果,即是正式的法庭审理程序适用几率会大幅度降低。但是“无论从刑事司法制度的历史发展角度、政治和社会需求角度我们都仍然需要和保持一系列恰当的程序来将犯罪与惩罚有机地联系起来”。^①正式法庭审判,将日益集中到严重刑事犯罪和被告人不认罪的刑事案件上。在此种背景下,刑事审判程序更应当成为实现司法公正、人权保障的载体,成为彰显公平正义的舞台,而这一切的前提则是刑事庭审实现“实质化”。

在全面推进依法治国背景下和新一轮的司法改革中,“刑事庭审实质化”的命题被推到风口浪尖。本文仅从制度层面,为庭审实质化的构建提供了初步改革方案。应当认识到,推进审判中心、实现庭审实质化是一项系统工程,其成功不仅有赖于上述诉讼制度的完善或改革,也要依托于司法体制、法官个人素养以及其他与法治因素息息相关的诉讼运行环境。

首先,从司法体制角度考察,审判独立是庭审实质化的制度保障和前提。换言之,如果没有独立审判,庭审实质化只能是空中楼阁。为此,在司法体制上要正确处理党的领导与公正司法的关系,建立地方党政机关、领导干部干预司法的阻隔机制。与此同时,还应理顺上下级法院之间的关系,废除提前介入、请示、报请制

^① 岳礼玲:《刑事审判与人权保障》,北京:法律出版社,2010年,第8页。

度,回归上下级法院之间法定的监督与被监督的关系。在此基础上探索司法人员的个体独立,实行法院司法事务管理权和审判权分离,使审判人员能够独立于本机关、本部门领导意志独立办案,即实现“法官独立”。

其次,从主体角度看,庭审实质化要求高素养的裁判者。庭审实质化意味查明事实、认定证据在法庭,要求裁判者在相关文书中阐释心证和结论,也意味裁判者将承担更多的责任。因此,法学素养不高的法官难以承受庭审实质化之重,道德有缺陷的法官甚至可能在“审判独立”、“庭审实质化”的面纱下滥用司法权杖。因此,如何提升裁判者的素养是“庭审实质化”命题下暗含的另一个重要课题。

再次,从程序保障角度考察,庭审实质化需要以完善的辩护制度和较为发达的法律援助制度为依托。庭审实质化要求认定证据在法庭、查明事实在法庭、裁判结果形成于法庭。因此,对于庭审的准备,尤其是审前控辩双方证据材料的收集以及控辩双方在庭审中的质证、辩论的专业素养对裁判结果起到决定性作用。就此而言,庭审实质化意味控辩双方的对抗性增强,庭审的技巧性甚至可能决定裁决的结果。为使被追诉人获得实质正义,有必要完善辩护制度,增强被追诉方收集证据的能力、拓展控方证据信息披露的途径和范围,同时完善法律援助制度,在扩大援助范围的基础上提升辩护的有效性。

最后,庭审实质化还需要与之对应的社会“容纳”环境。审判具有中立性和亲历性等特征,但是普通民众包括媒体对案件的判断有时具有间接性、情感性、非理性等特征。在畅通涉法涉诉信访渠道、建立穷尽法律救济程序后的依法终结制度的基础上,对案件处理过程中的社会舆论,司法机关同样应理性对待。与此同时,社会也应当尊重司法的权威性。为此,相关法律要规范媒体对案件的报道,媒体或舆论不得为吸引眼球采用带有倾向性、预判性的表述,不得煽动民意。在此基础上,对社会舆论要给予尊重并加以科学引导,实现司法与民意的有机、良性互动。唯有如此,才有可能为庭审实质化提供合适的土壤并使其生根。

〔责任编辑:刘 鹏 责任编辑:赵 磊〕